

1500527-85.2020.8.26.0062

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ KORTE

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... a consumo pessoal.

Ademais, o tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", prescinde da prova da mercancia (Jurisprudência em teses, STJ - Edição 131), bastando a demonstração de tal finalidade.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500527-85.2020.8.26.0062 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500527-85.2020.8.26.0062

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197205/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 12939193 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 3296/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2197205 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

CARLOS HUMBERTO BARONI e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

CARLOS HUMBERTO BARONI foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 12 de agosto de 2020, por volta da 1h, na rua José Messias de Almeida, 70, Jardim Beltrame, nesta cidade e comarca de Bariri/SP, mantinha em depósito para fins de tráfico de drogas, sem autorização legal, 24.06 g (vinte e quatro gramas e seis decigramas) da substância Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", divididas em 02 (duas) porções.

Defesa prévia à fl. 244.

Às fls. 253/254, foi recebida a denúncia.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas, às fls. 339/354, e, sustentando estar provada a materialidade e autoria, requereu a condenação do réu. Requereu o afastamento do privilégio do art. 33, §4º, da LD e a, ainda, a fixação do regime semiaberto.

A Defesa, por sua vez, nas alegações finais de fls. 363/368, requereu a absolvição, apregoando insuficiência do conjunto probatório; subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; a fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; além da detração do tempo de prisão provisória.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito se encontra formalmente em ordem, de modo que, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, não havendo, ainda, nulidade a sanar, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A existência do fato (materialidade) está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls.06/08, boletim de ocorrência de fls. 19/22 e fls. 17/21, auto de exibição e apreensão de fls. 22/24, auto de constatação preliminar de fls. 25/26, laudo definitivo da droga apreendida às fls. 132/135, relatório de investigações do aparelho apreendido com o réu (fls. 335/342), e, ainda, pelas demais provas coligidas em Juízo.

Passo, pois, ao exame da autoria.

Com relação à autoria, o réu, em seu interrogatório, declarou: “o que achou comigo é meu mesmo. O cigarro de maconha era para gente fumar. (...)”. Quando saiu com Valdir, a viatura encostou atrás. Valdir disse que tinha uma arma e “saiu de bicuda”. Valdir parou o carro e jogou a arma. “Foi isso mesmo, revistou, achou a arma, foi em casa e achou a maconha, que era para meu consumo”. O papel-filme era para enrolar a droga. Nunca vendeu droga. Trabalha como pintor. A balança de precisão era para pesar a droga, pois tinha “medo de ser passado para trás”. Já foi abordado outras vezes, mas nada havia consigo em tais ocasiões.

Entretanto, em que pesem as alegações defensivas, a prova produzida em Juízo comprova, com segurança, a autoria do crime do art. 33, caput, da LD.

Nesse sentido, a testemunha Murilo Bottura Leonel, policial militar, declarou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento em determinado bairro, quando avistaram um veículo. O condutor, ao ver a viatura, empreendeu fuga, e não respeitou os sinais sonoros e luminosos de parada. Efetuaram o acompanhamento por alguns quarteirões. Chegando próximo a um supermercado, o “veículo diminuiu a velocidade e arremessou um objeto”. Com apoio de outra viatura, conseguiram fazer a abordagem adiante, e no veículo estavam o réu e Valdir Bozza Júnior. Com Valdir, havia R\$ 2.047,00 em dinheiro, e com Carlos havia R\$ 230,00. No veículo também havia, ao lado do condutor, que era o lado de Valdir, um cigarro de maconha. Retornaram ao local onde dispensado o objeto, e lá localizaram um revólver Taurus, calibre .38, que a princípio estava “inoperante”. Foram até a residência de Carlos, e, lá, com a autorização da mãe de Carlos Barone, localizaram duas porções de maconha, uma balança de precisão e papel-filme transparente. Na casa de Valdir, com autorização da entrada, não localizaram munições nem drogas. Carlos é conhecido dos meios policiais. Costuma se evadir das abordagens policiais. O réu diz que vive de “rolo de veículos”. Já o abordou outras vezes, mas nas demais vezes não localizou drogas. Tentou abordá-lo outras vezes, mas o réu “corre da equipe”. A balança de precisão e o papel-filme estavam juntos, em uma caixa de papelão.

A testemunha Evandro Ricardo Leone, policial militar, prestou depoimento, em linhas gerais, no mesmo sentido da testemunha anterior. Acrescentou que a balança de precisão estava com “cheiro e resquício” de droga. Barone exerce atividade com veículos, “vira e mexe está com um carro diferente”. Sabe que, há um tempo, Carlos trabalhava como pintor. Quem estava dirigindo o veículo era Valdir.

Pois bem.

De início, registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, porquanto são testemunhas compromissadas assim como as demais, inexistente razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de seus relatos.

Nesse sentido, o TJSP: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Ademais, inexistiu nos autos prova de que tivessem a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime não cometido.

Veja-se que foram apreendidos objetos destinados ao embalo de droga e fracionamento, como a balança de precisão e rolo de papel-filme (que estavam, inclusive, acondicionados no mesmo local, conforme prova oral – auto de apreensão de fls. 22/24), indicativos de que o entorpecente, efetivamente, era destinado ao tráfico. Inverossímil, no aspecto, a alegação do réu de que a balança era utilizada para se certificar da quantia da droga, com medo de ser “passado para trás” (sic), até porque declarou ser usuário de drogas há bastante tempo, do que não se poderia se inferir não tivesse conhecimento daquilo que adquiria.

Isso não bastasse, houve apreensão de dinheiro em poder do réu (R\$ 230,00), e, para além disso, os diálogos extraídos de seu aparelho celular não deixam dúvida de que exercia o comércio espúrio.

Chama a atenção, ainda, as várias fotografias de dinheiro e entorpecentes havidas no aparelho móvel, como se vê às fls. 324, 325, a indicar um controle na aquisição e venda de drogas, típicos da atividade de comércio do entorpecente.

Afastando qualquer dúvida, colaciono os seguintes excertos do relatório de extração de dados do aparelho telefônico, de fls. 330/331:

Não há como olvidar que tais diálogos denotam que o réu atuava no fornecimento de entorpecentes a terceiros, inclusive com divisão de lucros em decorrência da comercialização, a exemplo do que demonstra o diálogo identificado pelo código PTT-20200717-WA0024.

Além do mais, não obstante o inconformismo do réu com a transcrição parcial de diálogos contidos nos dados telefônicos, não havia necessidade de transcrição integral pela Autoridade Policial. Se nem mesmo no âmbito das interceptações telefônicas há essa necessidade (STJ, HC 422.642/SP, j. 25/09/2018), idêntica conclusão se aplica em caso de quebra do sigilo dos dados do aparelho telefônico.

Basta que se confira às partes acesso aos dados, o que efetivamente ocorreu.

O fato de o réu eventualmente exercer trabalho lícito à época do flagrante, por si só, não tem o condão de afastar o fato típico, ilícito e culpável ora comprovado.

Portanto, e à luz dos parâmetros do art. 28, §2º, da Lei de Drogas (“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”), descabido falar de destinação exclusiva a consumo pessoal.

Ademais, o tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, prescinde da prova da mercancia (Jurisprudência em teses, STJ – Edição 131), bastando a demonstração de tal finalidade.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIAS SEPARADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014)." (STJ. HC 496.536/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Logo, cabalmente comprovada nos autos, pelos depoimentos já mencionados, apreensão de dinheiro e petrechos destinados ao embalo e fracionamento da droga, além dos diálogos contidos no aparelho celular, a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da LD.

Necessário apontar, ainda, que a condição de usuário não ilide necessariamente a de traficante e, não raras vezes, confunde-se no mesmo indivíduo, que faz do comércio ilícito a forma de sustentar o próprio vício.

É firme o entendimento de que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, bastando, para a incursão no crime de tráfico, que o agente incorra em qualquer das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, como ocorreu no caso. A corroborar o exposto: "A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício." (TJSP. Acórdão 1306853, 07244182520198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020).

Nesse caminho, mesmo se admitindo que o cigarro de maconha apreendido no veículo fosse destinado ao uso, tal não implica a descaracterização do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com base nos entorpecentes apreendidos na residência do réu.

Portanto, não cogito a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Presentes a materialidade e a prova segura da autoria do crime descrito na denúncia, cumpre examinar as questões relativas à tipicidade penal.

Nesse caminho, registro, desde já, ser descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 630 do STJ ("A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.").

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, o dispositivo prevê: "§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços (...), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.".

Com efeito, na interpretação da causa de diminuição de pena, deve-se atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que o objetivo legal foi de beneficiar com a sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de drogas, seja suficiente para a reprovação do comportamento. Afinal, rememore-se que a Constituição Federal possui mandado explícito de criminalização, com maior rigor penal, do tráfico de drogas, conforme art. 5º, XLIII.

Nessa toada, consoante definido pelo STF, 2ª Turma, no HC 154.694/SP, para fins do art. 33, §3º, da Lei de Drogas, milita em favor do réu a presunção de que é primário, possui bons antecedentes e não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus de provar o contrário é do Ministério Público.

No caso em tela, o réu é primário (fls. 185/186).

Entretanto, os diálogos extraídos do celular do réu demonstram, com suficiência, a dedicação a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da causa de diminuição. O relatório de fls. 322/335, realizado por mera amostragem, aponta múltiplos diálogos que demonstra uma atuação, prolongada no tempo, voltada ao fornecimento de entorpecentes a terceiros, inclusive com arrecadação de grande quantidade de dinheiro (imagens de fl. 324), além de exibição das quantidades de drogas em vários vídeos (fl. 326) e troca de imagens de arma de fogo no contexto da concertação de atos criminosos (imagens de fls. 326).

De fato, a grande quantidade de diálogos relacionados ao tráfico, contida no aparelho celular (notadamente os de fls. 330/331), demonstra que o réu se relacionava com inúmeras pessoas em prol da arrecadação de entorpecentes (são citadas várias pessoas, identificadas como "Nicolas", "Thurk", "Junho", "Dilmão", por exemplo), situação que denota, com segurança, a dedicação a que se refere o art. 33, §4º.

Face a tanto, diante de todos esses fundamentos, imperativo o afastamento do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

No mais, suficientemente comprovadas a existência e a autoria do fato descrito na denúncia, e não se verificando a ocorrência de causa ou circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, é peremptória a responsabilização penal.

Passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, art. 42 da Lei 11.343 e arts. 59 e 68, do Código Penal.

Dosimetria e individualização da pena

Na primeira fase, convém rememorar o art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

A natureza da droga (Cannabis Sativa) não impõe negatização; tampouco a quantidade apreendida.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos.

O réu não possui maus antecedentes.

Os motivos que o levaram a cometer o delito são normais à espécie.

As consequências foram normais.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

Não há falar em comportamento da vítima em tal espécie de delito (crime vago).

Logo, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, não estão presentes atenuantes ou agravantes, razão pela qual estabilizo a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento, tampouco causas de diminuição, uma vez afastada a hipótese prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Diante do exposto, na etapa final, fixo a pena final em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de elementos sobre a capacidade econômica do réu.

Regime inicial

Para a fixação do regime inicial, cumpre observar os critérios do art. 33, §§2º e 3º e art. 59, todos do Código Penal.

No caso dos autos, o réu é primário e não há adequação na fixação de regime inicial mais gravoso, mormente ante o quantum da pena.

Estabeleço, pois, o regime inicial SEMIABERTO, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Art. 387, §2º, do Código de Processo Penal

Não há falar em aplicação da regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal (detração penal) neste momento, porquanto o benefício não se confunde com progressão de regime; e, ainda, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme entendimento sedimentado da jurisprudência do STJ (HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Diante do quantum da pena aplicada, incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) e suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Indenização mínima

Em função de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação de valor para a reparação civil de ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conforme art. 387 do CPP, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu CARLOS HUMBERTO BARONI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

"Status Libertatis": pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos, e não havendo fato novo que altere o cenário, não estando presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal), poderá o réu recorrer em liberdade. Logo, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Transitada em julgado:

a) expeça-se a guia de execução;

b) intime-se o réu para pagamento da multa;

c) oficie-se ao IIRGD;

d) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Decreto o perdimento do valor apreendido e objetos apreendidos em favor da União.
Com o trânsito em julgado, oficie-se (Lei 11.343/06, artigo 63, § 1º).
Determino o perdimento da arma apreendida em favor do Comando do Exército (art. 25 do Estatuto do Desarmamento. Oficie-se.
Expeça-se certidão de honorários ao Defensor Dativo, conforme Termos/Valores do Convênio OAB/Defensoria, se o caso.
Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Bariri, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA